

1500908-06.2022.8.26.0618

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernanda Teixeira Salviano da Rocha

Comarca: Taubaté

Foro: Foro de Taubaté

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... procedência da ação penal. Quanto ao tráfico, asseverou que a versão fornecida pelo réu para justificar a posse da droga em sua casa diverge do acervo probatório - tais como as circunstâncias da abordagem, o encontro de instrumentos usados no tráfico e elevada quantidade de drogas variadas, que indicam ter ele ciência e adesão ao tráfico de drogas. Mesmo que assim ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2ª Vara Criminal DA COMARCA de Taubaté

Praça Monsenhor Silva Barros s/nº, Taubaté-SP - cep 12020-070

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500908-06.2022.8.26.0618 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500908-06.2022.8.26.0618

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2191412/2022 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 26143046 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 2191412 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, BO Nº: D06225-1/2022 - DEIC - TAUBATE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIOGO LEMES DE FARIA

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Teixeira Salviano da Rocha

Vistos.

DIOGO LEMES DE FARIA, qualificado nos autos às fls. 28, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, e no artigo 273, §1-B c.c. §1º, na forma do artigo 69 do Código Penal, sob a acusação de que, no dia 14 de julho de 2022, por volta das 13h51, na Avenida Marcílio Siqueira Frade, 738, Jardim Sandra Maria, nesta cidade e comarca, para fins de tráfico, preparava, tinha em depósito e guardava drogas, conforme laudo de constatação provisória (fls. 37/44), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta na denúncia que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, DIOGO LEMES DE FARIA importou, tinha em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribuiu ou entregou a consumo produto destinado para fins medicinais ou terapêuticos de procedência ignorada (quetamina e isoforina).

É da exordial que o réu decidiu dedicar-se ao narcotráfico, razão pela qual dispunha de drogas para venda e entrega a terceiros.

Narra a inicial acusatória que o réu despertou a atenção da Polícia Militar ao transitar na via pública com uma sacola contendo eppendorfs vazios. Todavia, não conseguiram abordá-lo, uma vez que ele entrou numa residência. Em seguida, os milicianos chamaram pelo morador, sendo atendidos por Osvaldo, o qual revelou ser pai do rapaz com a sacola de pinos plásticos e que ele havia acabado de sair da

prisão e não se envolvia mais com drogas, razão pela qual autorizou a entrada na casa. No quarto do réu, o indivíduo que transportava a sacola com os pinos, foram encontrados instrumentos comumente usados para confecção de porções de droga (rolo de filme plástico, rolo de papel alumínio, dois rolos com adesivos de caricaturas, duas fitas adesivas usadas, vários eppendorfs vazios), além de dois tijolos de crack, seis embalagens contendo cocaína, um "dixavador" e uma embalagem plástica contendo Cannabis Sativa L (maconha) fragmentada. Localizaram também os policiais: dois vidros contendo éter, duas embalagens de remédios e três frascos com líquidos transparentes (quetamina, isoforine e outra substância ainda não identificada, pendentes de confirmação por meio de laudo definitivo, cf. fls. 45/48). Indagado, o réu assumiu a propriedade das drogas e objetos encontrados, dizendo que era o trabalho dele.

Segundo a denúncia, formalmente interrogado, o réu permaneceu em silêncio (fls. 07).

Versa a exordial que o dolo de tráfico é percebido pela quantidade de drogas apreendidas, pela diversidade das substâncias entorpecentes localizadas em poder do réu, pelo modo de embalagem, pela apreensão de instrumentos comumente utilizados na confecção das porções de droga, dentre outras circunstâncias da prisão.

Após o oferecimento da denúncia (fls. 75/78), o réu foi devidamente notificado (fls. 92/93) e apresentou defesa prévia por intermédio de advogado constituído (fls. 113/119).

A denúncia foi recebida em 26 de agosto 2022 (fls. 130/132) e o réu foi pessoalmente citado (fls. 156).

Em instrução, foram ouvidas três testemunhas arroladas em comum pelas partes, uma testemunha arrolada exclusivamente pela defesa, e o réu foi interrogado.

Em sede de memorial escrito, o Ministério Público requereu, inicialmente, a juntada do laudo pericial definitivo nº 346.058/2022 (fls. 230/233). No mérito, requereu a integral procedência da ação penal. Quanto ao tráfico, asseverou que a versão fornecida pelo réu para justificar a posse da droga em sua casa diverge do acervo probatório – tais como as circunstâncias da abordagem, o encontro de instrumentos usados no tráfico e elevada quantidade de drogas variadas, que indicam ter ele ciência e adesão ao tráfico de drogas. Mesmo que assim não fosse, ele admitiu que guardava a droga em troca de dinheiro, configurando o crime. Quanto ao crime de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, sustenta que também restou devidamente demonstrado. A presença das substâncias apontadas na denúncia [quetamina e isoforine], de procedência ignorada, configuram o delito. Os elementos probatórios ainda vêm fortalecidos com a prova testemunhal dos policiais. Por outro lado, o depoimento da testemunha de defesa deveria ser analisado com cautela sobre a autorização de entrada na residência, pois trata-se de testemunha parcial (genitor), com nítido interesse na absolvição. Na dosimetria penal, requereu, na primeira fase, a fixação da pena-base acima do mínimo em razão de circunstâncias desfavoráveis (quantidade e qualidade das drogas); na segunda fase, requereu o agravamento da pena devido à reincidência e reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; na terceira fase, requereu o não reconhecimento do privilégio insculpido no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Postulou pelo regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda corporal.

Já a Defesa, também em sede de memorial escrito, requereu, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade por ausência de fundadas suspeitas para a realização da abordagem policial, bem como para a entrada dos policiais na casa. Salientou que os policiais, na realidade, ingressaram na garagem da casa sem autorização expressa do genitor, que havia deixado o portão aberto. Sustentou haver divergências nos depoimentos policiais realizados em solo policial e em Juízo. Requereu também reconhecimento de nulidade em razão de quebra da cadeia de custódia da prova, pois os entorpecentes submetidos à perícia seriam diversos e distintos dos apreendidos, tendo sido todos os itens acondicionados sob o mesmo lacre, não seguindo a individualização correta no manejo da prova. No mérito, quanto ao delito do artigo 273, §1-B c/c. §1º do CP, requereu a absolvição por ausência de materialidade, já que o resultado do primeiro laudo definitivo foi inconclusivo e do laudo

complementar ao definitivo foi no sentido de que “não foi possível identificar a presença de substâncias elencadas nas listas E/F da portaria SVS/MS 344/98 e suas atualizações, ou na portaria MJ/ 240-2019, em sua lista III, conforme portaria SPTC 136 de 03/08/2020”. Subsidiariamente, em razão de ausência de dolo, requereu a desclassificação para a modalidade culposa (artigo 273, § 2º, do CP). Quanto ao crime de tráfico de entorpecentes, na dosimetria penal, requereu, na primeira fase, a fixação da pena-base no mínimo legal por não haver circunstâncias desfavoráveis; na segunda fase, requereu a compensação da reincidência específica com a confissão; na terceira fase, sem considerações. Postulou pelo regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda corporal.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Da análise percuciente de todo o processado concluo que a pretensão punitiva Estatal é parcialmente procedente. Finda a instrução, restou devidamente comprovado nos autos que o réu cometeu parte dos delitos que lhe são imputados na inicial acusatória.

A materialidade do crime está positivada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/49), pela fotografia do réu (fls. 25), pelo laudo do exame cautelar de lesão corporal realizado no réu, que não constatou lesões corporais recentes de interesse médico-legal (fls. 27), pelo boletim de ocorrência (fls. 29/32), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 33/34), pela fotografia dos itens apreendidos (fls. 35), pelo laudo de constatação provisória de substância entorpecente nº 222.858/2022 (fls. 37/44 e 169/176) e os laudos complementares nº 222.869/2022 (fls. 45/46 e 167/168), nº 246.698/2022 (fls. 165/166), nº 263.282/2022 (fls. 163/164), pelo laudo de exame químico-toxicológico nº 269.169/2022, que constatou a presença das substâncias tetrahydrocannabinol (THC) e cocaína nos materiais apreendidos (fls. 179/183), pelo laudo de exame químico-toxicológico nº 346.058/2022 (fls. 231/233) e, ainda, por toda a prova oral colhida.

A autoria igualmente é certa.

O réu, na delegacia (fls. 07), optou por permanecer em silêncio.

Em audiência de custódia (fls. 66/67), informou que foi preso no dia anterior, dia 14, por volta das 13h15. Foi preso pela polícia militar. O tratamento pelos policiais militares foi tranquilo. Avisou sua família da prisão e conversou com seu advogado. Passou pelo médico legista. Foi encaminhado para a delegacia. Na delegacia o tratamento também foi tranquilo. É amasiado e sua companheira está grávida. Mora com seus pais. Tem 24 anos de idade. Trabalha com seu pai, instalando calhas. Tem passagem por tráfico de drogas, cumpriu pena e saiu da cadeia em dezembro. Com seu trabalho, aufera R\$ 120,00 (cento e vinte reais) por dia. Sabe o motivo de sua prisão. Foi preso em sua casa.

Em juízo, Diogo disse que tem 24 anos, já foi processado por tráfico de drogas, é usuário de maconha. Trabalha com seu pai, de calheiro. No dia dos fatos estava dentro de sua casa, na sala, sua mãe chegou para fazer o almoço. Ficou conversando com ela. Seu pai chegou do serviço, nervoso, dizendo que os policiais estavam lá e queriam conversar com ele sobre drogas. Eles estavam na garagem. O policial falou que tinha denúncia de droga e que ia vistoriar sua casa. Foi com ele até o quarto, confirmou que tinha uma bolsa no guarda roupa, em que estava guardando a droga. O dichavador e a maconha não estavam na mochila, eram do seu consumo. Mostrou onde estava a mochila, no guarda roupa. Na sala ele retirou as coisas da mochila.

Explicou que estava guardando a bolsa. Tinha uma dívida anterior, de dez mil reais. Assim que saiu o rapaz foi atrás dele. Conseguiu juntar e pagar dois mil reais com o seu trabalho. Um dia antes foi abordado, ele tinha uma arma no colo e falou para dar um dinheiro para ele, mas não tinha. Ele pegou uma mochila e uma bolsa e mandou guardar por dois dias. Não teve outra reação, ele com a arma no colo. Não sabia o que era, mas sabia que era droga. Explicou para o policial que o prendeu. Ele disse que ia diminuir a dívida se guardasse a droga. Estava devendo para "Buiú, Neguinho", a dívida era de antes da sua primeira prisão. Não sabe dizer o quanto está devendo agora. Está muito arrependido. Se tivesse oportunidade, teria pedido o dinheiro para o seu pai.

A testemunha Osvaldo, ouvido na delegacia (fls. 06), relatou que “na presença da

Autoridade Policial e do Advogado qualificado, disse que ao chegar em sua residência notou aproximação dos milicianos. Os policiais disseram que havia denúncia de drogas em sua casa. Declara que desconhecia a presença de drogas e qualquer ilícito no interior da casa, sendo que franqueou a entrada dos policiais na casa. Acompanhou as buscas dos policiais e presenciou o momento em que eles encontraram objetos aparentando ser drogas no quarto de seu filho Diogo. Novamente informa que desconhecia a presença de drogas na casa. Desconhece o envolvimento de seu filho com tráfico de drogas, tendo conhecimento apenas que ele é usuário de maconha. Informa que Diogo estava no imóvel no momento dos fatos, sendo abordado neste momento. Informa que com Diogo nada foi encontrado de ilícito. Nega qualquer envolvimento com o tráfico de drogas apurado e se compromete a comparecer em juízo quando notificado" (sic).

Em juízo a testemunha Osvaldo relatou que é pai do réu. Chegou do serviço, estacionou e os policiais chegaram com ele. Perguntaram seu nome, se era morador, disseram que tinham uma denúncia de droga na sua casa. Disse que não mexia com droga. Perguntaram se tinha um filho com passagem, confirmou, disse que ele saiu em dezembro. Pediram para chamá-lo. Os policiais estavam na garagem. Pediram para se afastar. Conversaram com seu filho. Pediram para acompanhar a busca. Entrou com eles. Foram direto no quarto do seu filho, acharam uma mochila com as drogas. Deram ordem de prisão para ele e disseram que ia a delegacia para dizer que os autorizou a entrarem. Fez isso. Na delegacia estava acompanhado de advogado, o Dr. Felipe mesmo. Na delegacia confirmou que eles autorizaram. Autorizou eles a entrarem porque não falou nada, acompanhou as buscas. Diogo estava trabalhando com ele. Na data dos fatos foi levar a mulher dele no médico, de manhã, por isso não foi. Ia na parte da tarde. Estacionou e os policiais pararam ao seu lado.

A testemunha Leandro, policial militar, ouvido em solo policial (fls. 04), relatou "que estava em patrulhamento com sua equipe pelo bairro Três Marias, quando avistaram um homem caminhando e carregando uma mochila nas costas e uma sacola plástica transparente com objetos coloridos em seu interior. Aproximaram a viatura, quando visualizaram que esses objetos eram eppendorfs vazios, momento em que o indivíduo adentrou na residência de numeral 738. Se aproximaram da casa e chamaram pelo morador, sendo atendidos por um senhor de nome Osvaldo. Perguntaram quem era o homem que acabara de entrar, sendo respondido que era o filho dele. O depoente informou que ele estava portando sacola com drogas e Osvaldo disse que seu filho havia acabado de sair da prisão e não se envolvia mais com drogas, franqueando a entrada da equipe na casa e acompanhando as buscas. A equipe vistoriou a casa, quando no quarto do homem que estava com os pertences citados, foram encontrados rolo de filme plástico, rolo de papel alumínio, dois rolos com adesivos caricaturas, duas fitas adesivas usadas; a sacola com vários eppendorfs vazios; dois tijolos de crack; seis embalagens contendo cocaína; um dixavador e uma embalagem plástica contendo maconha fragmentada; dois vidros contendo Eter; duas embalagens de remédios e três frascos com líquidos transparentes. Indagado, o indiciado assumiu a propriedade das drogas e objetos encontrados, dizendo que era o 'trabalho dele'. Diante dos fatos deu voz de prisão ao detido e conduziu até esta delegacia." (sic).

Em juízo o policial militar Leandro disse que viram o réu com uma mochila, ele demonstrou nervosismo e fugiu ao ver a viatura. Entrou na residência. O pai dele confirmou que o réu entrou, que já tinha sido preso por tráfico de drogas, mas que não fazia mais ilícito. Autorizou a entrada para vistoriar a mochila. O pai do réu os acompanhou. Dentro da mochila estavam os entorpecentes. O réu confessou, disse que ia fazer a venda. Não o conhecia. A bolsa estava semiaberta e foi possível ver o que pareciam ser eppendorfs. Havia bobina de papel filme para embalar bolas, substâncias como éter, usados para diluir a droga. Havia adesivos também. Uma cartela separada. Era uma bolsa grande e estava tudo dentro dessa mochila. Estava longe para dar ordem de parada, mas por serem coloridos conseguiram ver os eppendorfs. Gritar na rua seria difícil. Associou os pinos com a droga, presumiu que ele tinha drogas, e falou para o pai dele que ele tinha drogas. Não havia denúncias contra ele.

A testemunha Roger, policial militar, ouvido em solo policial (fls. 05), relatou

que “corroborar o depoimento do colega Cb Pm Costa, acrescentando que solicitaram a presença do genitor do detido, a fim de prestar declarações dos fatos ocorridos.” (sic).

Em juízo, o policial militar Roger disse que a equipe estava em patrulhamento, avistaram o réu com uma mochila. Chamaram na casa, saiu o pai do réu. Ele contou que o filho tinha sido preso, mas não mexia mais com droga. O pai autorizou a entrada e acompanhou a equipe. Acharam a droga. O réu confessou, disse que ia comercializar. Viram o réu entrar, foram se aproximando, o pai dele encostou o carro e estava entrando também. Chorou, falou que não era para o réu ter feito aquilo, que dava emprego para ele, que não precisava fazer aquilo. Não conhecia o réu. Estava com uma mochila nas costas e uma sacola na mão. Desconfiaram, a sacola era muito volumosa. O réu tinha instrumentos para fazer drogas, várias coisas, tudo junto na mesma mochila. Não conseguiram chegar perto, não viu se era, de longe parecia ser eppendorf. Ele não fugiu. Entrou na casa. Estavam se aproximando, o pai dele desceu do veículo, abriu o portão. O pai dele chegou um pouco antes.

Dichavador, um pouco de maconha, no guarda-roupa.

Ouvida somente em juízo, a testemunha Imaculada relatou que nesse dia o réu foi levar a mulher no médico. Estava na cozinha com ela quando seu marido entrou dizendo que os policiais estavam chamando o réu. Depois seu marido entrou com os policiais, que acharam uma mochila no quarto do réu. Quando foram tirar o que tinha na mochila saiu de perto.

Como se vê, não há a menor dúvida de que o réu praticou os delitos descritos na inicial acusatória.

Os elementos de prova coligidos nos autos conferem a certeza necessária para a condenação.

Os policiais estavam em patrulhamento de rotina quando se depararam com o réu caminhando pela via, com uma mochila nas costas e uma sacola plástica transparente nas mãos, que continha em seu interior microtubos vazios (imagens das sacolas com microtubos coloridos às fls. 35).

Então o réu, percebendo a aproximação policial, prontamente adentrou em uma residência. Os agentes se dirigiram até a referida residência e chamaram pelo morador, oportunidade em que foram atendidos pelo genitor do réu, testemunha Osvaldo, que chegava em casa.

Ato contínuo, Osvaldo concordou em franquear a entrada dos policiais no local e acompanhou as buscas no imóvel.

No quarto do réu, os agentes encontraram rolos de plástico filme e papel alumínio, adesivos com caricaturas, fitas adesivas, sacola plástica com microtubos vazios, dois tijolos de crack, seis invólucros de cocaína, um dichavador (moedor de maconha), um invólucro de maconha fragmentada, quatro frascos contendo líquido transparente desconhecido, dois frascos contendo líquido de nome éter sulfúrico comercial, um frasco com líquido de nome isoforine e um vidro contendo líquido de nome quetamina.

Informalmente inquirido pelos policiais, o réu assumiu a propriedade das drogas e outros materiais apreendidos, bem como alegou que a atividade ilícita era o trabalho dele.

Formalmente inquirido pela Autoridade Policial, o réu optou por permanecer em silêncio.

Em juízo, o réu confessou a prática delitiva do crime de tráfico de drogas, dizendo que recebeu as drogas e apetrechos para guardar, pois tinha uma dívida com traficantes.

Como se pode perceber, os policiais apresentaram versões firmes e coesas, narrando com riqueza de detalhes a forma com que ocorreu a abordagem do réu e a apreensão das drogas, no seu quarto dentro de sua própria residência, onde tiveram a entrada franqueada pelo genitor do réu, a testemunha Osvaldo.

É fato que existe no espectro jurisprudencial, corrente, embora minoritária, que questiona a validade da prova acusatória baseada na palavra de policiais, principalmente no que diz respeito aos crimes envolvendo entorpecentes.

Tenho para mim, no entanto, que o melhor posicionamento é o que não discrimina a qualidade dos depoimentos, de sorte que a palavra do policial, que depõe sob

compromisso, como testemunha, tem o mesmo valor que o de qualquer outra pessoa. Somente quando há divergências e contradições instaladas a partir do confronto de seus próprios depoimentos ou de suas declarações com os demais participantes da diligência, e essas são de tamanho relevo a determinar a imprestabilidade do testemunho, é que se deve desprezá-lo.

Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunhas a intenção de incriminar falsamente alguém. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição.

Sobre a questão, não é dispendioso trazer à liça o escólio do Supremo Tribunal Federal: "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência" (STF - Habeas Corpus nº 72.608-SP - Rel. Min. Celso de Mello).

Com efeito, "os funcionários da polícia merecem nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresenta razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador" (TJSP - Apelação Criminal nº 174.720-3 - Piracicaba - 4ª Câmara Criminal - Relator: Sinésio de Souza - 07.08.95 - V.U.).

Ora, os policiais não tinham motivos para incriminar o réu.

Além disso, o réu admitiu que guardava a droga e o pai do réu presenciou o encontro das drogas e apetrechos junto aos pertences do réu.

Portanto, a autoria delitiva está clara.

A tese da defesa quanto à irregularidade da entrada dos policiais na residência do réu não deve prosperar, uma vez que o depoimento dos policiais é justamente no sentido de que a entrada foi devidamente franqueada pelo morador Osvaldo (genitor do réu), o que foi confirmado por ele em solo policial e também em Juízo.

Em que pese a Defesa tente lançar o argumento de que a entrada não foi autorizada - uma vez que os policiais já teriam ingressado na garagem do imóvel quando o genitor entrou nas dependências do imóvel para chamar o réu -, tal versão não se sustenta, pois denota nítida tentativa de se macular o ingresso dos policiais e a consequente invalidação da prova colhida.

Conforme se observa dos autos, o genitor foi devidamente acompanhado por advogado para prestar depoimento em solo policial. Lá estando, contando com o suporte do causídico que acompanhou o ato, foi firme em declarar que houve autorização para ingresso dos policiais no imóvel, sequer mencionando a circunstância de que os policiais já estariam dentro da garagem ou que teria ocorrido qualquer invasão.

Causa estranheza a este Juízo que a versão da testemunha, em Juízo, tenha se modificado. Em Juízo, na presença do mesmo advogado que o acompanhou em solo policial, a testemunha passou a insinuar que a entrada dos policiais não foi autorizada, que não ficou claro que o genitor concedeu autorização para entrada, uma vez que os policiais teriam conversado em particular com o réu e depois simplesmente pediram para acompanhá-los na busca no interior do imóvel.

Tal contradição não permite inferir que, de fato, houve entrada irregular no imóvel. Se a irregularidade realmente estivesse presente, tal fato certamente seria consignado em solo policial pela testemunha, que estava devidamente acompanhada do mesmo advogado naquela oportunidade.

Perfeitamente justificada, também, a fundada suspeita, vez que os policiais perceberam que o réu transportava eppendorfs em sua sacola, razão pela qual foram em seu encalço.

Superado esse ponto, a preliminar da nulidade em razão da suposta quebra da cadeia de custódia também não merece prosperar.

Analisando detidamente os autos, percebe-se que as substâncias apreendidas contaram com números de lacres 0003135, 0003134, 0003133, 0002179 e 0002180, conforme auto de apreensão de fls. 33/34.

No momento da elaboração do laudo provisório, tais lacres foram devidamente identificados de acordo com as substâncias analisadas nos itens 1, 2, 3, 4, 5 e 6, inclusive contando com imagens da forma como estavam embaladas, sem quaisquer traços de irregularidade (fls. 37/44).

Da leitura do laudo provisório, percebe-se que constou expressamente que o material remanescente de todos os itens – que estavam devidamente acondicionados nos lacres 0003135, 0003134, 0003133, 0002179 e 0002180 – foram reunidos em um mesmo lacre, de nº 0159849, para fins de realização do laudo definitivo.

Posteriormente, observa-se da leitura do laudo complementar de nº 263.282/2022 (fls. 163/164) que “as amostras encontravam-se embaladas com lacre de número 0159849 e retornam em embalagem plástica vedadas com lacre de número 0157685”.

Então, no laudo definitivo de fls. 179/183 há a consignação expressa de que “todo material recebido encontrava-se acondicionado em invólucro plástico lacrado sob lacre 0157685”.

Observa-se, ainda, que na descrição dos itens constantes no laudo de fls. 179/183, são devidamente identificadas as descrições físicas de cada um dos objetos analisados (“invólucro plástico encerrando porção de material sólido particulado; invólucro plástico encerrando porção de material sólido petrificado; invólucro plástico encerrando porção de fragmentos vegetais ressequidos, constituídos de folhas, folíolos, inflorescências, caules e frutos; invólucro plástico encerrando 4 frascos transparentes cilíndricos com tampa contendo fração líquida translúcida e volátil; invólucro plástico encerrando 2 frascos vítreos fechados por batoque e tampa própria contendo fração líquida translúcida e volátil; invólucro plástico encerrando 2 frascos vítreos fechados por batoque e tampa própria contendo fração líquida translúcida e volátil”).

Ou seja, o caminho perseguido pelos elementos periciados foi documentado e explicado, não havendo qualquer evidência de mácula da cadeia de custódia da prova, motivo pelo qual a arguição de nulidade não merece prosperar.

Com relação ao crime do artigo 33 da Lei n.º 11.343/06, não restam dúvidas quanto à materialidade delitiva.

O tipo penal do tráfico de drogas é misto alternativo, e a realização de qualquer conduta já é suficiente para configurar o crime. Nestes autos, ficou claro que o réu tinha em depósito e guardava as drogas, sendo desnecessário ter sido flagrado em ato de venda.

Nesse sentido: Para a configuração do delito não se exige qualquer ato de tráfico, bastando que o agente traga consigo, transporte, tenha em depósito ou guarde a substância entorpecente, fazendo-se, também, inexigível, a tradição, para a consumação (TJSP, Ap. Crim. 899.394/0, 6ª Câ. Do 3º Gr. Da S. Crim., rel. Des. Marco Antonio, j. 25-10-2007, v.u., Boletim de Jurisprudência nº 136).

Cabe frisar que ele admitiu expressamente em Juízo que guardava as drogas em casa em razão de dívida que possuía do tráfico.

As drogas apreendidas foram analisadas em perícia técnica que reconheceu a ilicitude das substâncias. O laudo do exame de constatação provisório (fls. 37/44 e 45/46), retificado às fls. 165/166, e o laudo do exame químico-toxicológico (fls. 179/183) constataram a presença das substâncias tetrahydrocannabinol (THC) e cocaína nos materiais apreendidos.

As circunstâncias evidenciam o intuito da mercancia.

Sobreleva notar que a quantidade de droga apreendida (2,41g de cocaína em forma de material sólido particulado – crack – e 3,65g de maconha, fls. 165/166), a forma de acondicionamento, os objetos apreendidos (rolos de plástico filme e papel alumínio, adesivos com caricaturas, fitas adesivas, sacola plástica com microtubos vazios, todos comumente usados no narcotráfico), e as circunstâncias em que ocorreram os fatos (policiais estavam em patrulhamento de rotina quando visualizaram o réu na via pública segurando sacola com eppendorfs vazios, oportunidade em que, ao perceber a aproximação, entrou em uma casa; os policiais foram até a casa, onde foram recebidos pelo morador, genitor do réu, que franqueou a entrada, local em que

foram apreendidas as substâncias), evidenciam de forma clara o intuito da mercancia.

Deve o réu, portanto, responder pelo crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Com relação ao crime tipificado no artigo 273, §1º, c.c. §1º- b, inciso V, do Código Penal, entendo que este, por outro lado, não restou devidamente comprovado. Em que pese tenham sido apreendidas no quarto do réu as supostas substâncias quetamina e isoforine, além de outras substâncias líquidas e medicamentos de procedência ignorada e sem as características de procedência e qualidade, a materialidade destes crimes não foi demonstrada.

Conforme se extrai do laudo definitivo de fls. 179/183, em relação a todos os frascos transparentes contendo líquido, os resultados restaram inconclusivos.

Posteriormente, no laudo complementar ao definitivo de fls. 231/233 constatou, em relação às substâncias líquidas ali periciadas, que "A análise do material descrito fez o uso de Espectroscopia na região do Infravermelho com Transformada de Fourier e NÃO FOI POSSÍVEL IDENTIFICAR presença de substâncias elencadas nas listas E e F da Portaria SVS/MS 344/98 e suas atualizações, ou na Portaria MJ 240/2019, em sua lista III, conforme a(s) técnica(s) utilizada(s) (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020)".

Ora, levando em consideração que um dos pressupostos indispensáveis para a condenação em determinado delito é justamente a comprovação da materialidade, e que os laudos definitivos não constatarem a presença de substâncias quetamina e isoforine (constantes da denúncia), a sua absolvição quanto a este delito é medida que se impõe.

Portanto, deverá o réu ser responsabilizado apenas pela prática do crime previsto no artigo 33, caput da Lei 11.343/06, do Código Penal.

Passo à aplicação da pena.

Atenta aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal e ao disposto no artigo 42 da Lei 11.343/06, verifico que o réu ostenta antecedentes desabonadores (processo n.º 0005553-06.2017.8.26.0625, da Vara do Juizado Especial Criminal de Taubaté, cujo trânsito em julgado se deu em 14/02/2018, conforme fls. 56/57) e que, no momento do delito, o réu cumpria pena em regime aberto, de acordo com as informações do processo de execução criminal nº 0012691-87.2018.8.26.0625, sendo que foi posto em tal regime em 17/12/2021 (fls. 57), fato que demonstra que a conduta social do réu é mais reprovável, pois evidencia seu caráter desvirtuado, um verdadeiro comportamento social inadequado, descomprometido com o cumprimento da ordem e da lei, evidenciando não estar preparado para o retorno do convívio social, até porque, de acordo com o artigo 36 do Código Penal, o regime aberto se baseia na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado, ausentes ao réu. Além disso, deve ser sopesada, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza, variedade e a quantidade de entorpecentes, a personalidade e a conduta social dos agentes. Assim, deve-se considerar também a natureza deletéria de uma das drogas apreendida, cocaína em forma de pedra crack, que gera intensa e rápida dependência, acarretando condutas extremamente violentas nos casos de abstinência e que acaba empurrando os usuários a outros crimes violentos, a fim de obterem dinheiro para comprarem mais e mais drogas. Levo em conta ainda a variedade de droga apreendida (maconha e crack), o que aumenta a culpabilidade e as consequências do delito, indicando que o réu está mais inserido no mundo do crime, lidando com diversos tipos de drogas e alcançando um número maior de usuários, evidenciando sua maior dedicação em comerciar entorpecentes, em detrimento da saúde de terceiros. Desta forma, fixo a pena-base para este delito em 1/3 acima do mínimo legal, para que fique em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

A exasperação da pena base mostra-se necessária em razão da natureza da droga traficada, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça deste país.

Senão vejamos:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE EXASPERADA DE UM SEXTO. NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. COCAÍNA. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. PREENCHIMENTO DE SEUS REQUISITOS. INCIDÊNCIA DA



MINORANTE. CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM. 1. Mostra-se justificada a exasperação da pena-base além do mínimo legal baseada na natureza da droga apreendida - cocaína -, por se tratar de substância nociva à saúde do usuário, a teor do que preceituam os artigos 42 da Lei nº 11.343/2006 e 59 do Código Penal. 2. Trata-se o artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, de norma de direito material de observância obrigatória quando da fixação da pena nos delitos por ela regulados por imperativo constitucional, eis que beneficia o agente dada a possibilidade de redução da reprimenda. 3. Faz jus à diminuição da pena o paciente que preenche todos os seus requisitos, não sendo motivação idônea para se afastar a incidência da minorante a menção no sentido de ser o paciente detentor de maus antecedentes levando-se em conta condenação ainda não transitada em julgado. 4. Habeas corpus denegado, e concedida a ordem, de ofício, para aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, reduzindo a pena do paciente na ação penal de que aqui se cuida a 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa" (STJ, HC 152.285/SP, Ministro Relator Haroldo Rodrigues, j. em 23/02/2010 - destaquei).

O mesmo entendimento é compartilhado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"A reprimenda mostrou-se adequada e motivadamente dosada: pena-base fixada em 1/5 acima do mínimo legal pelos maus antecedentes (fls. 126 tráfico) e pela potencialidade lesiva da droga, acrescida de 1/6 pela reincidência (fls. 125 roubo circunstanciado), alcançando a pena final de 07 anos de reclusão; não aplicado o redutor previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, diante da reincidência. Assim sendo, e não se evidenciando erro técnico ou excessivo rigor, a punição deve ser mantida, tal como estabelecida" (14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação nº 0004327-68.2012.8.26.0292. Relator Des. Marco de Lorenzi. J. em 04/07/2013 - destaquei).

Ademais, a valoração negativa da conduta social do réu se encontra em plena consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL COMO VETORIAL NEGATIVA. LEGALIDADE. DELITO PRATICADO ENQUANTO O RÉU USUFRUÍA DA PROGRESSÃO DE REGIME PELO COMETIMENTO DE CRIME ANTERIOR. PRECEDENTES. 1. A valoração negativa da conduta social do agente se encontra adequada, pois fundamentada em elemento concreto, qual seja, o delito foi cometido enquanto o réu usufruía do benefício da progressão de regime, encontrando-se em cumprimento de pena por delito anterior. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido." (STJ, AgRg no HC n.º 556.444/DF, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 18/08/2020).

Tratando-se de réu reincidente específico (processo n.º 1500544-73.2018.8.26.0618, da 3ª Vara Criminal de Taubaté, cujo trânsito em julgado se deu em 02/09/2019, conforme fls. 58), circunstância que denota maior descaso com a Justiça e a habitualidade da prática delitiva, agravo a pena em 1/5, para que fique em 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 799 (setecentos e noventa e nove) dias-multa.

Presente a atenuante da confissão espontânea, compenso-a com a agravante da reincidência, para que a pena retorne ao quanto fixado na primeira fase da dosimetria, ficando em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Sobre a compensação: "EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. NOTÓRIO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. MITIGAÇÃO DOS REQUISITOS FORMAIS DE ADMISSIBILIDADE. ROUBO. CÁLCULO DA PENA. COMPENSAÇÃO DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. 1. Quando se trata de notório dissídio jurisprudencial, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça diz que devem ser mitigados os requisitos formais de admissibilidade concernentes aos embargos de divergência. Precedentes. 2. É possível, na segunda fase do cálculo da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal. 3. Embargos de divergência acolhidos para restabelecer, no ponto, o acórdão proferido pelo Tribunal local." (STJ. EResp n. 1.154.752/RS, Min. Rel. Sebastião Reis Júnior, j.

em 23/05/2012 – destaquei).

Em razão da reincidência e dos maus antecedentes do réu, inaplicáveis as benesses do artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, por expressa vedação legal.

À mingua doutras causas modificadoras da reprimenda, torno-a definitiva.

Fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena de reclusão, com fundamento no artigo 33, §2º, alíneas “a”, do Código Penal, em razão da quantidade de pena aplicada, por expressa determinação legal.

Ainda que se tenha que levar em consideração a detração prevista no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, para a fixação do regime inicial, neste caso, não haverá qualquer modificação fática, porquanto o réu é reincidente e o regime inicial para o cumprimento de sua pena continuaria sendo o fechado.

Nesta toada, não concedo ao acusado o direito de apelar em liberdade, ante a ausência de modificação do quadro probatório que motivou decretação da prisão preventiva, bem como pelo quantum de pena aplicada e o regime inicial do cumprimento da sanção corporal e sua espécie, pois o Tribunal da Cidadania firmou entendimento de que não há lógica em deferir a liberdade provisória ao sentenciado que respondeu ao processo preso preventivamente – precedentes: HC 453.891/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 03/12/2018; RHC 82.759/CE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., DJe 06/06/2018; RHC 94.655/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª T., DJe 06/04/2018. No mesmo sentir, da Suprema Corte, o RHC 121528, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª T., j. em 03/06/2014.

Aliás, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal” (AgRg no RHC 116.112/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª T. STJ, DJe 10/12/2019).

Não bastasse o sobredito posicionamento, com a prolação da presente sentença condenatória em cognição exauriente (após o exercício da ampla defesa e do contraditório), há inegável reconhecimento judicial da autoria e materialidade delitivas. Consequentemente, a custódia cautelar é a única medida possível para garantia da ordem pública. Pontue-se também que restou demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade do sentenciado, na medida em que ele se dedicava intensamente às atividades espúrias.

Acresça que, em caso de interposição de recurso por qualquer das partes, a prisão preventiva será convertida em execução provisória, nos moldes do Provimento 06/2000 c.c. o art. 470 das NSCGJ, e pelo disposto no art. 8º da Resolução 113/2010 do CNJ. Assim, inexistindo prejuízos ao sentenciado quanto a eventuais benefícios (RHC 111.134/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T. STJ, DJe 16/09/2019), não se cogita constrangimento ilegal com a ratificação do decreto de prisão preventiva, máxime pela satisfação dos pressupostos estampados na legislação de regência. Tendo em vista a fundamentada revisão, registro a interrupção do prazo de 90 (noventa) dias, que encontra previsão no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei Federal 13.964/2019). Assim, inicia-se a contagem de novo interregno de revisão de manutenção da prisão preventiva a partir da presente data.

Ausentes elementos que indiquem a capacidade econômica do réu a autorizar a majoração o dia-multa, fixo-o no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva Estatal contida na denúncia para CONDENAR DIOGO LEMES DE FARIA, filho de Osvaldo Prudêncio de Faria e Imaculada Lemes de Faria, RG n.º 50.158.604-0, nascido aos 26 de junho de 1998, natural de Taubaté/SP, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, ABSOLVENDO-O, todavia, da imputação prevista no artigo 273, §1-B c.c. §1º, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, III, do Código de Processo Penal.

Recomenda-se a manutenção do réu onde se encontra recolhido em razão da sentença condenatória.

Expeça-se a respectiva Guia de Recolhimento Provisória, nos moldes do Provimento 06/2000 c.c. o art. 470 das NSCGJ, e pelo disposto no art. 8º da Resolução 113/2010 do CNJ.

Ante a manutenção do réu no cárcere, deverá a Serventia inserir um alerta no Sistema Informatizado, para que se possibilite o controle do prazo de 85 (oitenta e cinco) dias, indicado no Comunicado CG n. 78/2020, bem como deverá encaminhar cópia deste feito à fila "acompanhamento de preventiva decretada", para eventual apreciação, se os autos ainda estiverem em primeiro grau.

Condene o réu a arcar, ao final da ação, com a taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 4º, §9º, alínea "a", da Lei n. 11.608/03.

Quanto aos eppendorfs e substâncias apreendidas (fls. 33/34), tratando-se de objetos que foram utilizados para a prática dos delitos, destrua-se.

Lance-se, com o trânsito em julgado, o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se o necessário para o cumprimento da reprimenda.

P. R. I. C. Oportunamente ao arquivo.

Taubaté, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA